



Numéro du dossier : 342.9-1081/20/22/8

Berne,

07. NOV. 2022

Décision

du Département fédéral de justice et police DFJP

dans l'affaire

Demande de MSC Mediterranean Shipping Company SA, 2 -14, chemin Rieu, 1208 Genève, (requérante)

représentée par Mes Louis Burrus et Giulia Marchettini, Schellenberg Wittmer SA, 15bis, rue des Alpes, Case postale 2088, 1211 Genève 1

concernant

une autorisation au sens de l'art. 271 ch. 1 du code pénal (CP ; RS 311.0)

I. Exposé des faits

1. Par requête du 10 octobre 2022, la requérante a formulé la demande suivante :

[...] MSC sollicite respectueusement du Département fédéral de justice et police la délivrance d'une autorisation au sens de l'art. 271 CP en vue de la production de documents situés en Suisse requis par MCS dans le cadre de la procédure initiée par devant U.S. Federal Maritime Commission aux Etats-Unis, portant la référence ("Docket No.") 21-05.

2. Selon les explications de la requérante, la procédure suivante est à la base de sa demande :

MSC est une société de droit suisse, d'envergure internationale, active principalement dans le secteur du transport maritime. MSC a été atraite par-devant la Commission maritime fédérale des Etats-Unis (US Federal Maritime Commission ; ci-après : la "FMC") par la société MCS Industries, Inc. [...] avec laquelle elle se trouvait engagée dans une relation contractuelle.

Au mois de juillet 2021, MCS Industries a introduit une action civile (private reparations action) à l'encontre de MSC, en se fondant sur des violations alléguées de la loi américaine de 1984 sur le transport maritime de marchandises (United States Shipping Act of 1984, 46 U.S. Code Sections 40101 et seq. ; ci-après "US Shipping Act"). Dans le cadre de cette procédure, MCS Industries fait notamment valoir devant la FMC des prétentions de nature civile, basées sur de supposées violations contractuelles qui auraient été commises par MSC et qui contreviendraient également au US Shipping Act.



L'affaire a été attribuée à la Juge Erin. M. Wirth (ci-après : "la Juge"), membre de l'Office des juges de droit administratif (Office of the Administrative Law Judges ; ci-après : l'ALJ"), organe dépendant de la FMC.

3. Selon les explications qui y figurent, les étapes de procédure suivantes ont précédé la requête :

Par motion du 22 novembre 2021, MCS Industries a requis de la Juge qu'elle ordonne l'administration de preuves, tant aux États-Unis qu'en Suisse. En particulier, MCS Industries a sollicité la production, par MSC, d'un large éventail de documents commerciaux internes (notamment des états financiers et des documents contenant des données de tiers).

Le 8 décembre 2021, la Juge a fait droit à la requête de MCS Industries et a ordonné à MSC de produire les documents demandés, dans le cadre toutefois des limitations temporelles, spatiales et matérielles sollicitées par cette dernière.

Le 31 mai 2022, une demande d'entraide, prérédigée par les conseils de MCS Industries, a été formée par la Juge et notifiée (par l'intermédiaire des conseils de MCS Industries) au Tribunal de première instance de Genève (TPI). Cette requête, basée sur la CLaH70, visait à ce que le TPI interpelle MSC afin que celle-ci fournisse des documents et des informations, puis réponde par écrit, sous serment, à des demandes de renseignements, en lien avec la procédure pendante devant la FMC.

Par décision du 29 juin 2022, le TPI a rejeté la requête d'entraide, au motif que la procédure pour laquelle l'entraide était demandée était "une procédure administrative instruite par un juge administratif rattaché à la Commission fédérale maritime des États-Unis" et, qu'ainsi, elle n'avait "pas trait à une cause civile ou commerciale et [n'entrait] ainsi pas dans le champ d'application de la CLaH70".

Le 15 juillet 2022, MSC et MCS Industries ont informé la Juge du rejet de la requête d'entraide par le TPI. En sus, considérant la décision du TPI comme erronée s'agissant de l'applicabilité de la CLaH70, MSC a, pour sa part, soutenu qu'une nouvelle demande d'entraide - exposant de manière plus détaillée la nature du litige et les compétences de l'autorité requérante - devait être soumise aux autorités suisses.

Néanmoins, par Order du 29 juillet 2022, la Juge a refusé de soumettre une nouvelle demande d'entraide aux autorités suisses et a ordonné à MSC de produire les preuves demandées avant le 29 août 2022.

A la suite de cette décision, MSC a décidé de solliciter de l'Office fédéral de la Justice (ci-après : l'OFJ) des clarifications concernant le champ d'application de la CLaH70 et la possibilité, pour l'autorité requérante, de resoumettre une nouvelle demande d'entraide. Une requête en ce sens a ainsi été envoyée au Domaine de direction Entraide judiciaire internationale de l'OFJ en date du 11 août 2022.

Le 25 août 2022, MSC a requis la prolongation du délai imparti au 29 août 2022 par la Juge pour produire les preuves requises, afin d'être en mesure d'obtenir les précisions complémentaires sollicitées de l'OFJ et de pouvoir, sur cette base, proposer une solution qui lui permette de fournir les documents demandés sans contrevenir au droit suisse.

L'OFJ a répondu à la demande d'information de MSC en date du 6 septembre 2022. Dans sa réponse, l'OFJ a d'une part confirmé qu'une nouvelle demande d'entraide pouvait être formée auprès des autorités suisses. D'autre part, l'OFJ a fourni une liste très détaillée des critères à prendre en compte pour déterminer si une demande d'entraide relevait ou non de la matière civile et commerciale au sens de la CLaH70.

[...]

La réponse de l'OFJ a été transmise à la Juge en date du 6 septembre 2022. Le 8 septembre 2022, la Juge a cependant rendu un nouvel Order dans le cadre duquel elle a rejeté la demande de prolongation de délai soumise par MSC, et imparti à cette dernière un délai de deux semaines - arrivé à échéance le 22 septembre 2022 - pour qu'elle fournisse les pièces requises ou démontre les raisons pour lesquelles un jugement par défaut ne devrait pas être prononcé à son encontre. L'Order du 8 septembre 2022 a également écarté l'avis de l'OFJ, jugeant qu'il présentait uniquement le processus pour soumettre à nouveau une demande d'entraide et les facteurs qui pouvaient être pris en compte dans ce cadre, sans aucune discussion sur le fond de la procédure.

II. Considérants en droit

4. Selon l'art. 271 ch. 1 al. 1 CP est punie toute personne, laquelle, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse, pour un État étranger, à des actes qui relèvent des pouvoirs publics. Cette disposition vise à empêcher l'exercice de la puissance étatique étrangère sur le territoire suisse et à protéger le monopole du pouvoir étatique et la souveraineté suisse. Un acte incombant à une autorité ou à un fonctionnaire est – indépendamment du fait qu'un fonctionnaire ait agi ou non – tout acte qui, considéré en soi, c'est-à-dire selon sa nature et son but, se caractérise comme une activité officielle. Ce n'est donc pas la personne de l'auteur qui est déterminante, mais le caractère officiel de l'acte. L'acte punissable doit être accompli pour un Etat étranger, c'est-à-dire dans l'intérêt de ce dernier. Les éléments constitutifs de l'infraction ne concernent que les actes accomplis sans autorisation de l'Etat (*cf.* ATF 148 IV 66 c. 1.4.1).
5. Conformément à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA ; RS 172.010.1), les départements et la Chancellerie fédérale décident, dans leur domaine, des autorisations de procéder pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics prévues à l'art. 271 ch. 1 CP. L'art. 31 al. 2 OLOGA dispose que les cas d'importance majeure, sur le plan politique ou autre, doivent être soumis au Conseil fédéral. La demande de la requérante relève du domaine de l'entraide judiciaire en matière civile, qui est de la compétence du DFJP. Il ne s'agit pas d'un cas d'importance majeure, ni sur le plan politique ni sur un autre plan. Le DFJP est donc compétent pour traiter la demande.
6. Selon une décision du Conseil fédéral du 25 juin 1997 (publiée au JAAC 61.82), une autorisation au sens de l'art. 271 ch. 1 al. 1 CP peut être octroyée à condition que la voie de l'entraide judiciaire ne soit pas exclue sur le principe et que, bien que pouvant être empruntée, elle soit pratiquement impossible ou vaine en l'espèce. Il en résulte qu'aucune autorisation ne peut être octroyée lorsque l'entraide judiciaire est possible.
7. C'est le cas en l'espèce. Comme la requérante indique elle-même, la voie de l'entraide judiciaire selon la Convention de La Haye sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale du 18 mars 1970 (RS 0.274.132) est ouverte. Contrairement à la décision du 29 juin 2022 du Tribunal de première instance de Genève, il s'agit en espèce d'une affaire civile et commerciale. La procédure étrangère concerne un litige entre deux sujets de droit privé résultant d'un rapport de droit privé sous forme de contrat. Il s'agit de dommages et intérêts, une créance typique du droit civil. Que l'*Office of the Administrative Law Judges* de la *Federal Maritime Commission* soit un tribunal civil ou – comme le nom le suggère – un tribunal administratif ne joue aucun rôle.

Ce qui est déterminant, c'est la nature de l'objet de la procédure (RODRIGUEZ, Commentaire Zurichois LDIP, 3ème éd., remarques préliminaires à l'art. 11-11d N 3 avec *références*). De plus, il est indiqué dans la requête qu'aussi la Cour suprême des Etats-Unis a qualifié, matériellement, les actions en dommages-intérêts devant la FMC d'actions civiles.

8. Dans la partie concernant l'application au cas d'espèce de la demande, il est également indiqué à juste titre que le rejet de la demande d'entraide judiciaire par le tribunal compétent n'a matériellement aucune force de chose jugée (*res iudicata*). Une demande d'entraide judiciaire peut être déposée à nouveau sous une forme améliorée. En l'espèce, il existe une réelle chance qu'une demande d'entraide judiciaire qui fonde l'existence d'une affaire civile et commerciale de la même manière que la demande présente soit acceptée par le tribunal.
9. Par conséquent, la demande doit être rejetée.
10. Conformément à l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (RS 172.041.1), toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument. En l'espèce, l'émolument est fixé à CHF 2000.- sur la base de l'art. 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0).

III. Décision

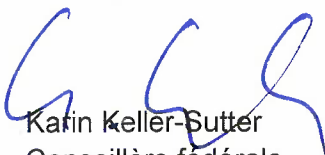
Vu ce qui précède, il est décidé :

1. La demande d'autorisation au sens de l'art. 271 ch. 1 CP est rejetée.
2. Les frais de procédure de CHF 2000.- sont mis à la charge de la requérante.

IV. Indication des voies de droit

La présente décision peut faire l'objet d'un recours écrit et motivé, dans les 30 jours à compter de sa notification, devant le Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall. La décision attaquée ainsi que les moyens de preuve disponibles seront joints au recours. Pour le surplus, il est renvoyé à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021).

Département fédéral de justice et police DFJP



Karin Keller-Sutter
Conseillère fédérale

Notification :

- à la requérante (par l'intermédiaire de son représentant légal, en deux exemplaires)

Communication :

- au Ministère public de la Confédération
- au Département fédéral des affaires étrangères, Direction du droit international public
- au Département fédéral des finances
- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche